

1502813-58.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... o aporte das informações sobre a prática de tráfico pelos réus, foram realizadas campanhas para averiguar a veracidade das informações e apurar os endereços dos acusados. O policial Maurício narrou, inclusive, ter visto João em situação indicativa de tráfico, mas na ocasião não procedeu à sua abordagem, pois estava sozinho. Somente após tais diligências, foi solicitada a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502813-58.2021.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2164316/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 18558382 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 3189/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2164316 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO ARY ANDREOLI e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

JOÃO ARY ANDREOLI, LEONARDO GUSTAVO GALDINO SERRA e Jefferson Willian de Oliveira, qualificados nos autos, estão sendo processados como incursos nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

João e Leonardo foram notificados pessoalmente (fls. 283 e 434) e apresentaram defesa (fls. 293/294 e 322/325). Jefferson foi notificado por edital e a Dra. Defensora Pública apresentou defesa prévia (fls. 441/444).

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2021 (fls. 445/446) e os acusados João e Leonardo foram citados (fls. 503 e 505).

Não localizado, Jefferson foi citado por edital (fls. 510/511 e 535), deferindo-se a antecipação de colheita probatória (fls. 550).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e interrogados os réus João e Leonardo, e, em seguida, determinado o desmembramento do feito em relação a Jefferson (fls. 550/552).

Em debates, o representante do Ministério Público postulou a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

A Defesa de João alegou nulidade do mandado de busca e apreensão e, por conseguinte, da prova obtida em seu cumprimento, requerendo a absolvição do acusado. Subsidiariamente, pleiteou a fixação da pena mínima legalmente cominada, com concessão das benesses legais.

A Defesa de Leonardo pugnou pela desclassificação da conduta imputada ao réu para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e absolvição no tocante ao delito de associação.

É o relatório.
DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/13), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), fotografias (fls. 38/44), informação de fls. 50/83, laudos periciais (fls. 363/372 e 543/549), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 536/542) e pela prova oral.

A autoria também é certa.

Interrogado em juízo, João Ary admitiu a propriedade dos entorpecentes encontrados em sua residência, aduzindo que a maconha se destinava ao seu uso e a cocaína, ao comércio espúrio. Contou que exercia a atividade ilícita há cerca de cinco meses para complementar sua renda. Negou possuir parceiros na empreitada criminosa e afirmou que costumeiramente adquiria cocaína de pessoa conhecida por CR7, a quem não conhecia pessoalmente. No tocante a uma conversa travada com CR7 sobre um quilo de entorpecente, disse que ele iria viajar e lhe ofereceu essa quantidade para pagamento quando fosse possível, todavia não pegou a droga. Aduziu que vendia drogas para Leonardo, seu cunhado, para o uso dele.

Leonardo negou os delitos e afirmou que era somente usuário de entorpecentes. Aduziu que as conversas trocadas com seu cunhado, o corréu João, eram atinentes à aquisição de drogas para seu próprio uso. Falou para João adquirir entorpecente de melhor qualidade e para que ele parasse de vender para dois rapazes pensando em seu próprio benefício e por temer ficar sem drogas para consumir. Comprava entorpecentes de outras pessoas, além de João, embora ele fizesse um preço mais baixo.

O policial civil Paulo relatou que a polícia recebeu informações acerca da perpetração de tráfico pelos corréus, em especial de cocaína, o que ensejou a solicitação de mandado de busca e apreensão em endereços relacionados a João, vez que não tinham sido obtidos os endereços dos demais acusados até aquele momento. Em cumprimento ao mandado, no quarto de João foram localizados as drogas, balanças de precisão e apetrechos comumente usados para embalar entorpecentes, além de dinheiro. A análise dos dados do celular de João revelou negociações de drogas entre ele e o acusado Leonardo, seu cunhado, bem como com contato identificado como CR7. Segundo dito informalmente por João, CR7 é o réu Jefferson. Ainda, vislumbra-se das conversas que João também abastecia traficante menores. Em outro aplicativo

foi encontrado um arquivo com os nomes e valores devidos por pessoas que trabalhavam para João no comércio espúrio. Outro policial civil realizou diligências prévias e viu João utilizando seu veículo para o transporte de drogas. Ao que apurou, Jefferson era fornecedor de João e havia prestação de contas entre eles. Leonardo atuava como sócio ou auxiliar de João na distribuição do entorpecente que era adquirido de CR7. A linha de telefone usada por Jefferson não estava registrada em seu nome e não foi possível localizá-lo. Não conhecia João anteriormente, contudo havia recebido de um informante imagens retiradas de redes sociais nas quais ele interagira com Leonardo, não juntadas aos autos para não comprometer o colaborador.

O policial civil Maurício narrou que recebeu informações de que os acusados estavam traficando e, diante disso, realizou campanhas com a finalidade de descobrir os endereços deles. Em uma delas, visualizou João entrando em uma biqueira com um pacote na mão e saindo dali sem nada. Na oportunidade, João estava usando o veículo dele, um Corsa prata, indicado nas denúncias como sendo o automóvel utilizado por ele para fazer o delivery de entorpecentes. Como estava sozinho, não efetuou abordagem. Em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, João estava na residência de sua genitora, onde ele morava na época, e no imóvel foram localizados os entorpecentes e apetrechos apreendidos. Havia grande resquício de droga dentro do guarda-roupa, denotando que João usava o móvel para fracionamento. O automóvel Corsa Prata pertencente ao acusado estava estacionado na frente do imóvel e foi apreendido. Na verificação dos dados do celular de João, vislumbrou conversas entre ele e Leonardo sobre peso e reclamação dos consumidores sobre a qualidade de drogas. Apurou que João seria um fornecedor intermediário para traficantes menores de Jaú e Bocaina e que CR7 o abastecia. Leonardo era conhecido do setor de investigações por ter sido preso por tráfico e foi identificado pela fotografia do contato de João, gravado como "Leo". Um informante forneceu características de Leonardo, aduzindo ser ele distribuidor e braço direito do corréu João, seu cunhado.

Pois bem.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade do mandado de busca e apreensão, como aventado pela defesa de João.

Como restou demonstrado pela prova oral, com o aporte das informações sobre a prática de tráfico pelos réus, foram realizadas campanhas para averiguar a veracidade das informações e apurar os endereços dos acusados. O policial Maurício narrou, inclusive, ter visto João em situação indicativa de tráfico, mas na ocasião não procedeu à sua abordagem, pois estava sozinho. Somente após tais diligências, foi solicitada a expedição do mandado, que, de resto, preenche os requisitos do artigo 243 do Código de Processo Penal.

Ademais, inexistiu vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos.

Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que estimula a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subsequentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

E, por óbvio, não foram as referidas denúncias que acarretaram a prisão do réu João, mas o encontro de drogas e apetrechos utilizados no comércio espúrio, tudo a corroborar as informações recebidas pelos policiais.

João confessou que a cocaína que tinha em depósito e guardava em sua residência era destinada ao tráfico.

Não merece acolhimento a negativa de João no que atine à associação imputada, tampouco sua tentativa de livrar o corréu Leonardo da responsabilização criminal.

É incontroverso que as conversas de fls. 57/60 foram travadas entre os corréus João e Leonardo, considerando o teor de pg. 56, da prova oral e do próprio relato dos acusados.

Do bem lançado relatório de informações de fls. 50/83, corroborado pela prova oral, extrai-se que Leonardo e outros traficantes “menores” revendiam os entorpecentes regular e constantemente para João, em associação.

Não merece guarida a alegação de Leonardo de que somente comprava droga para seu uso e que as conversas com João – acerca da baixa qualidade da droga e sobre pedido para que ele cessasse as vendas para outras pessoas - tinham o condão de evitar que ficasse desprovido de entorpecente. É certo que ele mencionou ter experimentado uma cocaína fornecida por João e reclamou que ela era ruim. Ocorre que, na mesma conversa, ele justifica saber da má qualidade por ter dado “um tiro dela”, explicação claramente desnecessária, caso tivesse adquirido apenas para o próprio consumo.

Os diálogos também revelam que Leonardo pede a João para não vender drogas a Gabriel e Maicon e para encaminhar mais compradores para se abastecerem com ele, salientando que tais vendas também beneficiarão João, a quem será repassado parte do montante angariado. Ele também orienta João a dizer que “cinquenta real é só co Leo. Só co Leo.”, consignando que assim ele também se favorecerá (Aí vindo na minha mão vai pa sua também).

No mais, nas próprias conversas entre João e CR7, seu fornecedor de entorpecente, ele menciona o repasse aos “moleques” e o lucro que terá com a soma do comércio praticado por eles e das vendas maiores que fará diretamente (pg. 53).

Vê-se, pois, provas suficientes da associação entre os acusados, não se tratando, bem se vê, de ajuste isolado ou casual.

Quanto ao tráfico imputado a Leonardo, embora o vínculo associativo acima mencionado revele fortes indícios deste delito também em relação a ele, há que se aplicar o princípio do “in dubio pro reo” para afastá-lo.

Como já mencionado, as conversas extraídas do celular de João revelam que, além de repassar as drogas a Leonardo e outros indivíduos, ele também fazia a venda diretamente a usuários. No diálogo mantido com CR7 no dia anterior à sua prisão, João menciona ter apenas cerca de 100 gramas (de cocaína) em sua posse (quantidade semelhante à que foi apreendida com ele) e indica duas pessoas a quem irá fornecer essa droga (pg. 53), nenhuma delas o corréu Leonardo.

Nesse contexto, há dúvida quanto à efetiva participação de Leonardo no tráfico imputado a João no dia dos fatos.

Assim, a ação deve ser julgada parcialmente procedente para o fim de condenar o réu João pelos crimes narrados na denúncia e Leonardo apenas pelo delito de associação.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Nesta primeira fase, não verifico razões contundentes para majoração das penas-base, que fixo no mínimo legal em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa em relação ao

delito de tráfico imputado a João, e em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, no tocante à associação, para cada um dos réus.

Na segunda fase, para ambos, presente a agravante descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que o delito foi perpetrado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo), ressaltando-se, sobre ela, a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobre o tema na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos". Portanto, majoro as reprimendas para 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa (tráfico), e 3 anos e 6 meses de reclusão e 816 dias-multa (associação).

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão em relação a João, pois parcial e qualificada.

Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da comprovação de que João se dedicava à atividade criminosa de tráfico em associação com Leonardo e outros indivíduos.

Nesse sentido:

Apelação 990081551276 Relator(a): André Carlos de Oliveira, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 29/05/2009, Data de registro: 04/08/2009. Ementa: "TRÁFICO DE DROGAS. "Natureza, Variedade e Quantidade da Droga. Circunstâncias da Prisão. Condições econômicas das agentes. É intuitivo, pela natureza e quantidade da droga (maconha, 16,94 kg), sua disposição (distribuídas em 12 tijolos), ocultação (malas de viagem), que se destinava ela ao tráfico ilícito e clandestino. PROVA. Policiais Militares. É sem sentido desprestigiar depoimentos de policiais militares, os quais, até a abordagem, desconheciam completamente o recorrente e motivo algum, particular e infundado, possuíam para falsamente incriminá-las. Credenciados pelo Estado, critico seria a negativa de prestarem versão sobre condutas profissionais que realizaram. Associação para o tráfico. Perfeitamente possível o concurso material do crime de tráfico, do artigo 33 da Lei de drogas, com a associação do artigo 35 da mesma Lei, em especial porque provado, no particular, a divisão de tarefas, submissão a tarefas adrede atribuídas a uma e outra apelante, com recebimento de paga pela disposição em traficar. Tráfico e Associação. Redução de pena com fundamento no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. Impossibilidade. O fato de se reconhecer o crime de associação refuta, só por si, a causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas. É que o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 nada mais do que o crime de bando ou quadrilha dessa Lei, induzindo à conclusão de que não se justifica a benesse da redução da pena".

Presente o concurso material entre os delitos, as penas do réu João deverão ser somadas, totalizando 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição, pelo que torno definitiva a pena acima fixada para o réu Leonardo.

A despeito da primariedade dos réus, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado. O crime para o qual os réus estavam associados, tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo, é a principal causa de inúmeros outros delitos, notadamente patrimoniais, e gera efeitos nefastos para a sociedade e para as

famílias. Leonardo já foi condenado em primeiro grau por tráfico e, como já mencionado, as provas demonstram que os acusados estavam associados, de forma estável e permanente, para a prática do comércio ilícito, que exerciam com assiduidade, conforme demonstram os diálogos interceptados. A fixação de regime mais brando é, portanto, incompatível com a gravidade e reprovabilidade de sua conduta e não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

“O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão”

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para

fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim sendo, por entender que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de:

- 1) CONDENAR, como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material, o réu JOÃO ARY ANDREOLI, qualificado nos autos, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, no mínimo legal;
- 2) CONDENAR, como incurso no artigo 35, "caput", da Lei nº 11.343/06, o réu LEONARDO GUSTAVO GALDINO SERRA, qualificado nos autos, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 811 dias-multa, no mínimo legal e;
- 3) ABSOLVER o réu LEONARDO GUSTAVO GALDINO SERRA da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

Os réus não poderão apelar em liberdade, pois permaneceram presos no curso do processo e remanescem os requisitos que ensejaram sua custódia cautelar, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública. Recomendem-se, pois, na prisão em que se encontram.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, decreto, em favor da União, o perdimento do veículo Corsa Prata (fls. 18/20), usado na prática dos delitos, do celular e demais objetos e valores apreendidos.

Custas ex lege.

Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 04 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA